

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、電話線を盗む目的で、電柱に架設されていた電話会社所有の電話線を切断しているところを警察官に発見された。甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。
2. 甲は、深夜、金品窃取の目的で電器店に侵入し、懐中電灯で真っ暗な店内を照らしたところ、陳列棚に電気器具類があることを認識したが、なるべく現金を盗みたいと思い、歩いてレジの前に至ったところで警備員に発見された。甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。
3. 甲は、夜間、一人で歩いていたV女を見付け、約5キロメートル先のひとけのない工事現場にV女を連れ込んで不同意性交することを決意し、V女を殴って失神させた上、近くに停めていたダンプカーの助手席にV女を乗せて発進させた。甲には不同意性交等罪の実行の着手が認められる。(改)
4. 甲は、Xの住んでいる家を焼損する目的で、これと約50センチメートル隔てて隣接している木造物置小屋の中のわらや薪に灯油をまいて放火したが、物置小屋の一部を焼損するにとどまった。甲には現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
5. 甲は、登校中の子供に毒入りジュースを飲ませてこれを殺害する目的で、前日の夜に、夜間是人通りのない通学路に致死量を超える毒を混入させたペットボトル入りのジュースを置いた。甲には殺人罪の実行の着手が認められる。

No128	実行の着手	正答率
H26-9	正解 5	87%

1 正しい

最決昭31.10.2。窃盗罪の実行の着手は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が認められる行為を行った時点で認められる。判例は、「被告人は……電柱に架設中の電話線を切断窃取しようとしたが、巡査に発見逮捕されてその目的を遂げなかつたというのであつて、被告人は窃盗の目的で、他人の財物を切断しようとしたというのであるから、このときすでに窃盗の着手があつた」としている。

2 正しい

最決昭40.3.9（百選I 61事件）。判例は、侵入窃盗の事案において、侵入しただけでは足りず、遅くとも財物の物色行為のあった時点では着手が認められるとしている。もっとも、物色行為がなければ着手が認められないとするわけではない。判例は、本記述と同様の事案で、「電気器具商たる本件被害者店舗内において、……電気器具類が積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので……煙草売場の方に行きかけた際、本件被害者らが帰宅した……のであるから、……被告人に窃盗の着手行為があつたものと認め」られるとしている。この判例は、屋内で金品の存在しそうな場所に移動したところで着手を認めたものと評されている。そうすると、歩いてレジの前に至った場合、屋内で金品の存在しそうな場所に移動したといえるため、実行の着手が認められ得る。

3 正しい

最決昭45.7.28（百選I 62事件）。不同意性交等罪の手段たる暴行・脅迫には、性交等行為を可能にさせる客観的の事情が必要である。判例は、本記述と同様の事案において、「被告人が同女をダンブカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦〔注：不同意性交〕に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦行為〔注：不同意性交行為〕の着手があつたと解する」として、実行の着手を認めている。

4 正しい

大判大12.11.12。判例は、住宅に延焼させる目的で物置に放火し、物置の一部を焼損した事案において、現住建造物放火罪の未遂が成立するとしている。本記述では、甲は、Xの住んでいる家を放火する目的で、近接する物置小屋に放火し、その一部を焼損するにとどまっているが、上記判例に従えば、甲には、現住建造物であるXが居住する家に対する放火の実行の着手が認められ得る。

5 誤っている

宇都宮地判昭40.12.9。裁判例は、父及び弟妹らの日常通行する農道の道端に毒入りジュースを置き、拾得飲用させて殺害しようとした事案において、「農道に単に食品が配置されたというだけではそれが直ちに他人の食用に供されたといえない」として、殺人罪の実行の着手は認められないとする。「農村においては野ねずみ、害虫等の駆除のため毒物混入の食品を農道に配置することもあるであろうし、道に棄てた物を必ずしも人が食用に供するとは限らない」からである。本記述では、前日の夜に夜間人通りのない通学路に致死量を超える毒を混入させたペットボトル入りジュースを置いたにすぎないから、直ちに他人の食用に供されたといえず、実行の着手は認められない。